Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Balcão virtual (51) 997893836 - Email: frpoacent6vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000594-27.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: SANDRA REGINA DUARTE NETZ

RÉU: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

SENTENÇA

SANDRA REGINA DUARTE NETZ ajuizou **ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais** contra UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA aludindo que foi diagnosticada pela primeira vez em 2007 com neoplasia maligna de mama. Em 2020, a patologia teve recidiva e, em 2023, novamente teve recorrência. Recebeu prescrição médica de radioterapia, além da necessidade de cirurgia e tratamento medicamentoso contínuo. Contou que solicitou à demandada o fornecimento dos remédios Fulvestranto 500mg IM a cada 28 dias e Abemaciclibe 150mg de 12/12 horas. Disse ainda que o procedimento cirúrgico foi agendado para janeiro de 2024. Referiu que enviou a documentação em 14/11/2023 para o centro clínico indicado pela demandada, não havendo autorização por falha no pedido médico, ante a ausência de detalhamento justificando a necessidade da medicação. Mencionou que o segundo pedido foi formalizado em 25/11/2023. Nesse período, e diante da urgência, realizou a aquisição dos medicamentos por conta própria, no valor de R$ 22.076,00. Em 29/12/2023, realizou uma terceira solicitação à Unimed, uma vez que o anterior havia sido novamente negado, sob o mesmo fundamento (falha no detalhamento médico justificando a necessidade). Após a terceira solicitação, foi autorizada a cobertura do Fulvestranto, estando o outro medicamento prescrito em análise. Discorreu sobre a necessidade do tratamento com os fármacos prescritos pelo médico. Postulou a concessão da tutela de urgência para que a demandada forneça os medicamentos prescritos. Teceu considerações sobre o Código de Defesa do Consumidor e sobre os danos morais suportados. Requereu a concessão da gratuidade judiciária e a procedência dos pedidos (evento 1, INIC1). Juntou documentos.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida e determinada a citação (evento 4, DESPADEC1).

A autora informou o não cumprimento da decisão liminar e requereu o bloqueio de valores a fim de custear os medicamentos (evento 12, INIC1), o que foi indeferido (evento 15, DESPADEC1).

A autora novamente informou o não cumprimento da decisão liminar no prazo concedido (evento 19, INF1), razão pela qual foi deferido o bloqueio de R$ 22.076,00 para o custeio do tratamento (evento 22, DESPADEC1), cuja quantia foi levantada pela requerente (evento 34, DESPADEC1).

A tutela de urgência deferida foi complementada para que a demandada forneça os medicamentos enquanto persistir a necessidade (evento 41, DESPADEC1).

A parte ré contestou o feito. Preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, argumentou que não houve negativa do plano de saúde, mas sim o envio de documentação incompleta e incorreta pela parte autora. Discorreu sobre a ausência de falha na prestação dos serviços. Apontou que o contrato da parte autora não é regulamentado pela Lei dos Planos de Saúde, devendo observar, portanto, as cláusulas contratuais. Disse que a situação vivenciada pela autora não se caracteriza como de urgência ou emergência. Referiu que o reembolso deve ocorrer nos limites estabelecidos no contrato. Rechaçou a pretensão indenizatória. Requereu a improcedência da ação (evento 51, CONT1). Juntou documentos.

Sobreveio réplica (evento 55, RÉPLICA1).

As partes foram intimadas para dizer sobre a produção de provas (evento 57, DESPADEC1).

A UNIMED requereu a substituição da Unimed-RIO pela Unimed-FERJ no polo passivo (evento 60, PET2) e juntou documentos.

A autora requereu o julgamento do feito e não concordou com a substituição processual postulada pela Unimed (evento 65, PET1).

A demandada reiterou o pedido de retificação do polo passivo e informou não ter mais provas a produzir (evento 66, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido inicial comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porquanto a prova documental produzida nos autos é suficiente ao desate da controvérsia e as partes não manifestaram interesse na dilação probatória.

Impugnação ao valor da causa

A parte ré impugnou o valor atribuído à causa, com o fundamento de que o valor do custeio do tratamento é imensurável, dada a ausência de conhecimento pelas partes do prazo de duração do tratamento, que não pode ser presumido. Requereu a atribuição do valor de alçada à causa.

A pretensão autoral está consubstanciada na cobertura dos medicamentos enquanto necessários ao tratamento de saúde, ao ressarcimento do valor desembolsado com a aquisição dos medicamentos em face da demora no atendimento da solicitação pela parte ré e indenização por danos morais.

No caso em questão, aplica-se o disposto no art. 292, do CPC, especialmente, no inciso VI e § 2°, uma vez que, nas ações em que há cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder a soma destes e, se a obrigação for tempo superior a um ano, deverá ser igual à prestação anual.

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA CONTRATUAL.* ***Valor da causa. Nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, deve corresponder ao custo de 12 meses do tratamento, considerando que o medicamento será utilizado por tempo indeterminado.*** *Embora o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS constitua apenas a referência básica para os planos privados, conforme redação expressa do § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, este mesmo artigo de lei, em seu inciso VI, autoriza às operadoras dos planos de saúde a exclusão de cobertura para fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados os tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral e medicamentos de uso em home care. Medicamento prescrito para o tratamento de câncer avançado de rim (AFINITOR) que está incluído na categoria dos antineoplásicos, enquadrando-se na hipótese de exceção prevista pela legislação para cobertura de medicamento de uso domiciliar. Sentença confirmada. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50158595920228210027, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 29-11-2023) Grifei.*

Com efeito, a autora somou o valor mensal dos medicamentos ao montante postulado a título de ressarcimento e indenização por danos morais, totalizando R$ 54.152,00.

Ocorre que, tratando-se de obrigação de fornecimento de medicamentos por tempo indeterminado, o valor deve ser o da prestação anual, atingindo o montante de R$ 264.912,00. Acrescida a quantia pretendida a título de ressarcimento e a indenização por danos morais, chega-se ao valor de R$ 296.988,00.

Desse modo, acolho parcialmente a impugnação ao valor atribuído à causa, o qual retifico, de ofício, para R$ 296.988,00.

Retificação do polo passivo

A UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA postulou a retificação do polo passivo para UNIMED - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (FERJ).

Não há necessidade de retificação do polo passivo, considerando que a demandada UNIMED-RIO e UNIMED-FERJ pertencem ao mesmo conglomerado econômico. No caso, não se olvida a aplicação da Teoria da Aparência nas situações em que o consumidor, de boa-fé, não possui o discernimento sobre as peculiaridades das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico ou as áreas em que cada uma dessas empresas atuam dentro da sua relação comercial.

Assim, deixo de acolher o pedido de retificação do polo passivo, sobretudo diante da não concordância da parte autora.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que incidem à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a situação dos autos se enquadra no disposto pelo seu art. 3º, § 2º, devendo, portanto, as cláusulas contratuais respeitarem as regras dispostas na legislação consumerista. Nestes termos, também, a Súmula 608 do STJ: *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

No que concerne ao caso sob exame, analisando a prova documental apresentada pelas litigantes, verifica-se que a autora é beneficiária de Plano de Assistência Integral firmado com a requerida (evento 51, ANEXO3).

Como é possível extrair da análise dos documentos anexados à peça defensiva (evento 51), o referido plano de saúde fora contratado em 21/04/1994 (evento 51, ANEXO4).

E por ter sido contratado antes da entrada em vigor da Lei n.º 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), configura um plano de saúde não regulamentado, ou seja, as coberturas ficam limitadas àquelas expressamente previstas no instrumento contratual.

O art. 35 da Lei dos Plano de Saúde, por sua vez, assim dispõe:

> *Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.*

De outro vértice, há recentes julgados do STF em que consolidado o entendimento de que as regras estabelecidas pela Lei n.º 9.656/1998 se restringem aos contratos celebrados após sua vigência, mas que o abuso de cláusula contratual prevista em contratos celebrados anteriormente pode ser aferido de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor, especificamente em seu art. 47, que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

A título exemplificativo, colaciono as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. ***As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.*** *3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP. nº 1.349.647/RJ, Relator Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, Dje 23/11/2018) Grifei.*

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. 'É nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor' (REsp 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, Dje 28/06/2013. ***3. 'Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento'*** *(AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.027.161/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe de 25/05/2017). Grifei.*

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE LEI 9.656/98, ART. 35. CONTRATOS ANTERIORES. NÃO. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 535. NÃO OCORRÊNCIA. [...] ***2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência, mas a abusividade de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor.*** *3. Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a cirurgia ao qual foi submetido o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde do tratamento de quimioterapia indicado pelo médico que assiste o paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1.214.119/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015) Grifei.*

Além disso, há entendimento jurisprudencial no sentido de que compete às operadoras de planos de saúde adaptarem os contratos antigos às exigências mínimas na Lei n.º 9.656/1998, porquanto se caracterizam como relações de trato sucessivo com renovações periódicas. Sobre este ponto:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL. PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL BILATERAL NÃO CIMENTADA. PRÓTESES. ATO CIRÚRGICO. COBERTURA DEVIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do seu artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõem a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2. Aplica-se a Lei 9.656/98 aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente à sua vigência em razão destes serem de trato sucessivo e haver previsão de renovações automáticas, as quais ocorreram quando já em vigor a novel legislação, devendo a esta se adaptarem. ***Ademais, é incumbência da operadora comprovar que ofertou a possibilidade de adaptação do plano nos termos legalmente exigidos. Caso em que aplicável a novel legislação.*** *3. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. 4. Nessa senda, tem-se que próteses ligadas ao ato cirúrgico — incontroversamente o caso dos autos, conforme recomendado no atestado de fl. 15 —, nos termos do que dispõe o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, não podem ser excluídas da cobertura ofertada pelos planos de saúde. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079717385, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 18/12/2018) Grifei.*

RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO EM PERIODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 9.656/98. RADIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DEVER DE ASSEGURAR O CUSTEIO. NÃO CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA ADAPTAÇÃO AOS NOVOS PLANOS, CASO EM QUE NÃO SE EXCLUI A COBERTURA EM HIPÓTESES DE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 1. Narra a parte autora ser beneficiária de plano de saúde junto à Ré, e que em agosto de 2013, fora diagnosticada com câncer de mama. Aduz que a requerida autorizou o pagamento da cirurgia, negando, todavia, o custeio do tratamento quimioterápico, sob a justificativa de que o contrato da autora previa exclusão desta cobertura. Afirma que realizou o tratamento, arcando com as despesas. Pugna a condenação da ré no reembolso dos valores gastos com o tratamento, exames, consulta e transporte, em dobro, bem como indenização pelo dano moral. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autora, condenando a ré no pagamento do tratamento quimioterápico e afastando a indenização por danos morais. ***3. O contrato em tela deve ser interpretado favoravelmente ao segurado hipossuficiente, art. 47 CDC, pois, o contrato de plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco contratado e impõe a boa-fé e a clareza das informações prestadas pelos contratantes****. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 35 da Lei 9.656/98 e Súmula n. 469 do STJ. 4. Após a entrada em vigor da Lei dos Planos de Saúde – Lei 9.656/98 -, os contratos antigos devem ser adaptados à nova legislação e, principalmente, interpretados sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do princípio da boa-fé. Dever anexo de informação. 5. A ré traz aos autos provas de que ofertou a adaptação e migração do plano de saúde, todavia, a oferta foi endereçada à contratante Segurança Vêneto Ltda. e não a todos os beneficiários do pacto firmado por essa, entre eles a demandante. Assim, não restando comprovado pela operadora que tenha sido oferecida à autora a possibilidade de adaptação do contrato, é de se considerar que o plano de saúde da requerente, enquadrado na categoria dos contratos de trato sucessivo e de renovação periódica, passou a vigorar com as coberturas mínimas estabelecidas pela aludida modificação legal. 6. Ademais, os planos de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e a negativa de cobertura, nos moldes do art. 51, inc. IV, do CDC é abusiva, razão pela qual é procedente o pleito autoral de devolução dos valores despendidos provados nos autos. 7. No que tange aos danos morais, vai provido o recurso da parte autora, pois, evidentes os danos extrapatrimoniais na espécie. A ação da ré coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade e impotência, circunstâncias capazes, por si só, de romper o equilíbrio psicológico de qualquer pessoa, ainda mais daquela*

que já se encontra desestabilizada emocionalmente em razão de doença. Precedente: Recurso Cível Nº 71002432698, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 15/07/2010. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006960421, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 26/04/2018) Grifei.

É incontroverso nos autos que a autora foi diagnosticada com câncer de mama em 2007 e, desde então, vem realizando o tratamento pelo plano de saúde, indicativo, portanto, da cobertura para a patologia em questão.

Restou evidente também a necessidade da realização do tratamento com utilização dos fármacos Fulvestranto 500mg IM para uso a cada 28 dias e Abemaciclibe 150mg de 12/12h, para uso diário (evento 1, OUT11), cujo fornecimento foi pleiteado pela parte autora.

Em que pese a demandada sustentar a ausência de negativa no fornecimento dos medicamentos, refere na sua peça defensiva que o tratamento solicitado não é de cobertura obrigatória, o que configura a sua pretensão resistida:

> *Ainda, mesmo que fosse enviado os documentos corretos e todos os esclarecimentos solicitados, tudo indica que, **de acordo com o contrato, os tratamento solicitados, não são de cobertura obrigatória**, conforme comprovam os documentos em anexo.*

Além disso, restou demonstrada a demora no atendimento do protoloco de solicitação do medicamento formulado pela autora, que realizou 3 pedidos (evento 1, OUT10), o primeiro ainda em novembro/2023, sendo que em 04/01/2024, o pedido relativo ao Ademaciclibe ainda se encontrava pendente (evento 1, OUT5 - p. 6; evento 12, OUT3).

Com efeito, em que pese a inaplicabilidade da Lei n.º 9.656/98 acima mencionada, descabe eventual negativa de cobertura das despesas concernentes ao custeio do tratamento recomendado pelo médico assistente (evento 1, OUT11), pois a escolha deste ocorreu em razão da adequação ao quadro clínico da parte demandante.

Portanto, considerando a indicação médica, necessária se mostra a cobertura (fornecimento do medicamento), pois se está a tratar de um bem de hierarquia superior que é a saúde humana.

Outrossim, é pacífico o entendimento na jurisprudência do STJ no sentido de que não cabe à operadora de plano de saúde delimitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, mas tão somente estabelecer o tipo de doença que terá cobertura no contrato celebrado entre as partes.

De amparo, cito:

> *PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.*
> *1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais.*
> *2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.*
> ***3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.***
> *4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.*
> *5. Agravo interno no recurso especial desprovido.*
> *(AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019) Grifei.*
>
> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. CÂNCER DE MAMA. RECUSA INADMISSÍVEL. DANO MORAL.*
> *OCORRÊNCIA.*
> ***1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais.***
> *Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).*
> *(AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento.*
> *3. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser reconhecida a existência de dano moral.*
> *4. Não se pode reputar, diante do caso concreto, como excessiva a quantia fixada, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) 5. Agravo interno não provido.*
> *(AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Grifei.*

E, nesse aspecto, é incontroverso que o contrato vigente possui previsão de cobertura para o tratamento do câncer, inexistindo negativa nesse sentido.

No mais, a tese ventilada pela parte ré de que a autora deu causa à demora no fornecimento da medicação não se sustenta, tendo em vista que nenhuma prova nesse sentido aportou aos autos, ônus que incumbia à demandada (art. 373, II, do CPC).

Ainda, no que se refere à urgência, está comprovada pelo receituário médico acostado ao evento 1, OUT11:

> Atesto para os devidos fins que a Sra. Sandra Netz é portadora de Neoplasia de mama Bilateral com lesões em linfonodos de cadeia mamaria interna direita e esquerda e linfonodos axilares a direita e metastases em pele de região torácica, estádio IV. Em novembro de 2023 solicitei o protocolo de tratamento para a UNIMED RIO com as medicações: 1) Fulvestranto 500mg IM a cada 28dias e 2) Abemaciclibe 150mg de 12/12H uso diario. As medicações serão utilizadas ate a progressão da doenca ou toxicidade. Caso a paciente não receba ambas as medicações com urgência o caso ira se agravar e comprometer orgãos vitais.

Portanto, cabe à demandada o fornecimento dos medicamentos Fulvestranto 500mg IM para uso a cada 28 dias e

Abemaciclibe 150mg de 12/12h, para uso diário, enquanto persistir a necessidade da demandante.

Nesse cenário, também é cabível o ressarcimento do valor desembolsado pela autora com a aquisição dos fármacos, em razão da demora da demandada no atendimento da solicitação.

O valor de R$ 22.076,00 (evento 1, NFISCAL4) deverá ser restituído à autora com correção monetária pelo IPCA (índice oficial adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado para correção dos débitos judiciais, forte no art. 507, da Consolidação Normativa Judicial - CGJ/RS) a contar do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Por fim, no que se refere à pretensão indenizatória, cediço é que o mero descumprimento contratual não enseja indenização, ressalvadas hipóteses em que demonstrada a gravidade da situação a que submetida a parte.

No caso dos autos, a demora injustificada no atendimento da solicitação da parte autora enseja danos morais indenizáveis, em razão do agravamento da aflição e angústia da segurada que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade e, sobretudo, por se tratar de pessoa idosa.

Nesse sentido, cita-se:

> *APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). RECUSA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS VERIFICADOS. - Da impugnação ao valor da causa: O caso em análise trata de pedido de cumprimento de contrato de plano de saúde, consubstanciado no fornecimento um número determinado de unidades do medicamento Spravato®, cumulado com pedido de indenização pelos danos morais alegados. Neste viés, o valor da causa deverá ser fixado em consonância com a previsão contida no art. 292, VI, do diploma processual. Preliminar rechaçada. - Do dever de cobertura: No caso dos autos, se está diante de hipótese de aplicação de medicamento em ambiente ambulatorial ou hospitalar, pela impossibilidade de uso domiciliar. Assim, não se tratando de medicamento de uso domiciliar é devida a cobertura do fármaco Spravato® (Cloridrato de Escetamina). - Dos danos morais: No que se refere à pretensão de condenação da operadora de saúde ao pagamento dos danos morais, recordo que, via de regra, o mero descumprimento contratual não gera danos morais, pois, para a configuração desse dano extrapatrimonial necessária a comprovação de circunstância excepcional. Essa situação excepcional se verifica dos autos, pois a parte autora viu-se em situação de extraordinária angústia e humilhação.* ***Danos morais verificados. - No que se refere ao quantum indenizatório, deve ser fixado em valor que repare os transtornos experimentados pela parte no caso concreto, sem implicar enriquecimento ilícito e com a suficiente carga pedagógica. A quantificação deve levar em conta o caráter repressivo e educativo, o tempo de duração da ilicitude, a situação econômico/financeira do ofensor e do ofendido, bem como a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido. Quantum fixado em R$ 8.000,00.*** *PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50302945520238210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 25-04-2024) Grifei.*

Para a quantificação do valor indenizatório, deve-se levar em conta o caráter repressivo e educativo; tempo de duração da ilicitude; situação econômico/financeira do ofensor e ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido, dentro outros, evitando-se, todavia, o enriquecimento ilícito.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a indenização de R$ 5.000,00 indeniza o prejuízo sofrido, bem como pune de forma pedagógica a parte ré.

O valor fixado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (índice oficial adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado para correção dos débitos judiciais, forte no art. 507, da Consolidação Normativa Judicial - CGJ/RS) a contar da presente data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

O arbitramento da condenação em valor menor do que o postulado não importa decaimento (Súmula nº 326 do STJ).

No que se refere aos honorários sucumbenciais, considerando o alto valor atribuído à causa, a sua média complexidade, o tempo de duração e a ausência de dilação probatória, desproporcional a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa ou da condenação, deve esta ser feita de forma equitativa porquanto inestimável o proveito econômico da demanda, já que se trata de ação na qual o pleito é, em suma, é o fornecimento de tratamento medicamentoso e a garantia do direito à vida e à saúde da parte autora.

Diante do exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na ação ajuizada por SANDRA REGINA DUARTE NETZ em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA para

a) RATIFICAR as tutelas de urgência concedidas no evento 4, DESPADEC1 e evento 41, DESPADEC1;

b) CONDENAR a parte ré à cobertura integral do tratamento indicado à parte autora, com o fornecimento dos medicamentos Fulvestranto 500mg IM para uso a cada 28 dias e Abemaciclibe 150mg de 12/12h, para uso diário, conforme prescrição médica, enquanto persistir a necessidade;

c) CONDENAR a parte ré à restituição do valor de R$ 22.076,00, com correção monetária pelo IPCA a contar da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA a contar da presente data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Condeno a ré ao pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa, que fixo em R$ 8.441,84, conforme tabela de honorários da OAB/RS, versão 2023, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente data, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do

trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC), observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e singeleza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §§2º e 8º, do CPC).

Tendo em vista a sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º, do CPC, em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se à intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Com o trânsito em julgado, nada requerido no prazo de 5 dias, e satisfeitas eventuais custas pendentes, baixe-se.

Caso não seja efetuado o pagamento das custas, oficie-se ao TJRS, a fim de informar o não pagamento, nos termos do Ato n.º 072/2022 - P.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FABIANA LANGE VICENTE, Juíza de Direito**, em 13/6/2024, às 18:57:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10061057656v25** e o código CRC **f9848fbc**.